

<문제1>

I. 설문 (1)

1. 문제의 소재 - 甲 침해금지 및 손해배상 청구

(1) 法92조 -乙' 침해'가 성립되어야 함 (A-A'유사가정)

(2) (사안) 甲의 디자인권은 비밀디자인 등록되었고, 전용실시권 설정되어 있으므로 이를 검토함

2. A 비밀디자인권 관련 甲 청구의 적법성 (이하 본안요건과 함께 검토) ★(분량조절)

(1) 법적 근거 - 法 43조1항, 제113조제2항, 제116조제1항단서

(2) 비밀기간 내의 침해인 경우만 문제됨

1) 침해금지청구권 행사시 특허청장으로부터 증명받은 서면을 제출해야 적법함

2) 손해배상청구권 행사시 과실 또는 고의를 입증하는 증거를 제출해야 인용됨

3. 丙 전용실시권 관련 甲 청구의 적법성 ★

(1) 법적 근거 - 法 92조단서, 113조, 115조1항

(2) 전용실시권이 발생되었는지 - 法98조1항2호상 丙 발생

(3) 전용실시권기간 내의 침해인 경우만 문제됨

1) 문제점 - 디자인권자의 침해금지청구권이 인정되는지, 손해가 발생하는지

2) 학설 및 판례 - 독점권설 있으나, 판례는 배타권설(2006도1580), 정액매수시 디자인권자 손해없음(90가92251)

3) 사안

: 丙 전용실시권 불구 甲 침해금지청구권 행사 적법함.

甲 손해배상청구권 丙과 정률계약시 인용될 수 있음.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - A 등록결정의 공정력

2. 공지부분(이하 B)를 포함한 A의 권리범위 ★(분량조절)

(1) 권리범위(法92조상 동일, 유사), 신규성(法33조1항각호)

(2) 권리범위 속부판단시 공지부분의 취급 판례 (2003후762) - 중요도 낮게 평가, 제외한 나머지 특징적인 부분과 대비되는 부분이 비유사하면 속하지 않음

3. 창작이 용이한 A의 권리범위 ★

(1) 권리범위 부정 가부 - 소극 (2002후2037, 디자인판례)

(2) 자유실시디자인항변 - B로부터 A' 용이창작시 A권리범위 대비 없이 속하지 않음(2016후878)

(3) 보론 - 권리범위확인심판청구 이익여부, 권리남용항변 가부 - 적극/소극(2012후4162 특허 판례) : 창작이 용이한 A의 침해금지 등의 청구는 권리남용이고 청구할 이익이 없다는 견해가 있으나, '권리범위' 속부를 판단하는 절차에서 청구할 이익이 있고, 권리남용의 대인적 항변은 심리범위가 아니다.

Ⅲ. 설문(3)

1. 문제의 소재 - 신규성(法33조1항각호) - '유사' ★

2. 신규성에 관한 주관적 판단기준

(1) 견해 대립 - 당업자설/일반수요자설

(2) 판례 - 일반수요자설 (85후101 등)

3. 신규성에 관한 객관적 판단기준 ★

(1) 판례 - 전체적 대비관찰 및 요부관찰 (85후101 등)

(2) 보론 - 유사범위의 폭을 좁게 보아야 하는 경우 (옛,단,다,구/기, 2010도12633 등)

4. 丙이 무효심결에 대하여 취할 수 있는 조치 ★★

(1) 심결취소소송의 주체가 될 수 있는지 - 당/참/거(法 166조2항)

(2) 丙의 보조참가가 적법한지 (法 143조 3항, 甲측 이해관계, 무효심결확정시 전용실시권자로서 금지권 소멸)

(3) 丙이 심판에 참가한 경우 - 심결취소소송 제기

(4) 丙이 심판에 참가하지 않은 경우 - 甲 독촉, 甲대위청구

(5) 甲이 소송을 제기한 경우 - 丙참가(甲측 보조참가)

<문제2>

I. 설문 (1)

1. 문제의 소재

논점 추출 -> 확대된 선출원, 선출원, 선출원이 공개될 경우 신규성이 문제될 수 있음

2. 법적 근거 - 法 제33조3항, 제46조 제33조1항각호 (부분-法2조1호괄호)

확대된 선출원주의, 선출원주의, 신규성

3. 설문 1)의 해결

(1) 부분디자인과 전체디자인

(2) 사안의 경우

1) 선출원주의

: 물품 동일, 형태 비유사 -> 적용X

2) 확대된 선출원주의

: 선출원인 전체디자인의 일부와 후출원의 기능 및 용도 동일, 형태 동일, 후출원에 상당하는 부분이 대비할 수 있을 정도로 특정된 것을 전제로 하였을 때, 선출원이 후출원 이후에 디자인공보에 게재되어 공개된 경우 -> 적용O

3) 신규성

: 선출원의 전체디자인이 후출원 전에 공지 또는 공연 실시 된 경우를 전제로 하여, 후출원의 부분디자인A가 공지된 전체디자인에 포함되어 공지됨 -> 적용O

4. 설문 2)의 해결

(1) 부품디자인과 부분디자인

(2) 사안의 경우

1) 선출원주의

: 형태가 유사하나, 부품과 부분은 전체와 부분과의 관계 -> 적용X

2) 확대된 선출원주의

: 후출원인 부분이 선출원인 부품의 일부로 볼 수 없음 -> 적용X

3) 신규성

: 선출원이 후출원 전에 공지 또는 공연실시된 경우를 전제로 하여, 상호간 유사한 디자인 -> 적용O

(3) 결어

부분디자인과 부품디자인의 경우 사실상 동일·유사한 객체에 대하여 디자인이 중복 부여된 경우에 해당되므로 선출원 규정을 적용하여 후출원의 디자인 등록을 저지하는 것이 바람직할 것임.

II. 설문(2)

1. 92조 + 부분디자인권의 효력

2. 설문 1)의 해결

(1) 직접침해의 성립요건 -유/권/보/업/제

: 보호범위 내의 실시인지 여부가 문제임

(2) 보호범위 내의 실시인지 여부

: 부품과 부분의 경우에는 전체와 부분의 관계이므로 물품이 비유사하여 보호범위 내의 실시X

(3) 사안의 경우

: 직접침해 인정 X BUT, 부품이 부분디자인의 물품의 생산에만 사용되는 것일 경우를 전제로 하여 간접침해 인정여하 O

(4) 결론

: 부분디자인권자는 부품을 실시하는 자에게 침해 주장을 하지 못하므로, 디자인 등록을 받고자 하는 '부분'이 독립성 및 호환가능성이 있는 경우에는 '부품'으로 출원하여 등록받아야

3. 설문 2)의 해결

(1) 문제의 소재

직접침해 성립X, BUT 丙이 甲보다 후출원·후등록권리자이므로, 이용관계 성립여부 판단

(2) 이용관계의 의의 (法 제95조 제1항)

(3) 이용관계의 요건

1) 광의의 요건

2) 협의의 조건- '이용'의 의미(判例만 간략히)

(4) 사안의 경우 및 효력

1) 이용관계 요건 성립여하

2) 이용관계 성립시 효력

① 甲(선등록권리자) -> 적극적, 소극적 권리 제한 X. BUT, 丙의 디자인과 동일·유사한 디자인 실시시 침해 성립가능하나, 크로스라이센스 언급

② 丙(후등록권리자) -> 소극적 권리 제한X. BUT, 적극적 효력은 제한되어 '허락' 또는 '통상실시권허락심판'에 의하지 아니할 경우 적법한 실시가 될 수 없음.

<문제3>

I. 설문 (1)

1. 문제되는 거절이유(法2조1호,33조1항본문,40조1항) 일반론 간단히

2. a (2013허242) ★★

(1) a는 식품디자인인지 - 적극

(2) 法2조1호의 물품성 중 구체성 유무 - 적극(형태가 일정범위 내로 고정)

(3) 法33조1항본문의 공업성 유무 관련 공업적 방법에 의한 것인지(적극)

: (수공업 포함, 원료육 물리적변화, 식자재로서 유용한물품)

(4) 동일한 형태의 물품인지 - 적극

: (당업자동일성 인정, 냉동으로 판매단계까지 형상 유지가능)

3. b(93후1247) ★★

(1) 法33조1항본문의 공업성 유무 관련 공업적 방법에 의한 것인지 - 적극

: (결합 이전 상태로 판단해야, 연결핀과 고정구를 각각 반복하여 계속 제조할 수 있음)

(2) 法40조1항의 1디자인 유무 관련 1물품 여부 - 적극

: (물리적으로 1개인 것이 아니고 용법에 따른 결과와 무관, 용도와 구성상 기능적 일체성 있음)

II. 설문(2)

1. c(2003허3938)

(1) 法33조1항본문, 法93조상 공업성 중 구체성 판단기준 - 당업자 요지 특정

(2) 사안

: 상부 측 도면 불일치 및 하부측 도면 불일치상 요지 특정 불가능,

2. d

(1) 서비스디자인 의의 : 포/배/변

(2) 손수건 자체의 형태가 아니라 강아지 또는 배 모양의 형태로 상업적으로 변형된 손수건의 형태이므로, 法2조1호의 물품성 중 구체성, 형태성, 法33조1항본문의 공업적

생산X

3. e

: 法33조1항본문의 공업성 중 반복생산가능성 X - “광장에 설치한” 미술작품으로 동일한 형상으로 복제될 수 없는 순수미술저작물이라면 반복 생산 X

Ⅲ. 설문(3)

1. 디자인등록출원된 경우 조치 - 정보제공(法55조) 및 우선심사신청(法61조1항2호, 출원인이 실시(준비)중인 사정 있는 경우)
2. 디자인등록된 경우 조치 - 일부심사등록디자인인 경우 이의신청(法68조) / 무효심판(法121조, 이해관계인 기준 판례)

Ⅳ. 설문(4)

1. 문제의 소재 - 구체성의 법적근거: 法2조1호의 물품성 중 구체성, 法33조1항본문의 공업성 및 法93조상 구체성
2. 구체성 흠결시 취급 - 거/정/이
3. 무효사유 해당 여부 - 法121조1항2호, 구법 및 문제점, 01'개정법 및 타당성
4. 구체성이 일부 결여된 경우 완화 논의 (정정불가)
(1) 학설(정정설, 부정설)/ 판례(당업자경험칙상요지특정가능해야, 2004후2123) / 검토

<문제4>

I. 설문(1)

1. 디자인보호법상 캐릭터 보호의 필요성
2. 등록받는 방법
 - (1) 캐릭터 자체
: 캐릭터 자체는 추상적 모티브에 불과 -> 디자인의 성립요건 충족X
 - (2) 물품에 표현
: 개별적 물품에 표현할 경우 등록 가능 -> BUT, 法92조에 따라 물품이 비유사한 경우에는 침해 주장할 수 없음
 - (3) 특유디자인
 - 1) 부분디자인
 - 2) 동적디자인
 - 3) 화상디자인
3. 등록요건 (=> 관련있는 조문 최대한 많이 포섭해주면 됨)
 - (1) 공업상 이용가능성
: 캐릭터 자체를 출원할 경우 정의규정 위반으로 공업상 이용가능성 위반으로 거절될 여지 0

(2) 유사판단-선출원주의/관련디자인

: 디자인의 동일·유사는 물품의 동일·유사를 전제로 하므로 물품이 비유사한 경우에는 해당 조문이 적용될 여지X

(3) 신규성

: 신규성의 인용참증은 공지'디자인'(法2조1호)이므로 캐릭터 자체가 공지 또는 공연실시되었다는 사정만으로 신규성X

(4) 창작비용이성

: 캐릭터 자체가 주지하더라도 캐릭터가 구체적으로 묘사된 소설(글)은 캐릭터의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 아니므로 창작비용이성의 인용참증이 불가능하여 창작비용이성으로 거절될 가능성 X

(5) 부등록사유(法34조1호 내지 3호)

(6) 法40②

: 물품명을 기재할 경우 '캐릭터'가 아닌 캐릭터가 표현된 '물품'을 기재함

4. 결어

: 캐릭터를 보호하고자 할 경우 다양한 물품에 등록받아야 하며, 부분디자인, 화상디자인 등 특유디자인으로도 보호할 수 있다. 최근 2021년 10월 시행 개정법에서 화상디자인을 정의규정에 신설한 바, 더욱 효과적으로 보호될 것임.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 공동창작자/이전받으면 디자인권공유, 甲이 단독출원인 경우 문제됨

2. 甲과 乙과의 관계 -저작권자와의 이용/저촉

: 선 발생한 저작권과의 이용관계 성립가능

(1) 甲의 효력 - 法 95조 3항

1) 적극적 효력

: 제한됨

-> 통상실시권허락심판 인정하지 아니하므로 '허락'에 의하여만 가능

2) 소극적 효력

: 제한 x

(2) 乙의 효력

: 적극적, 소극적 효력 제한되지 아니함.